

1500869-98.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... o tema, é relevante observar que o tráfico muitas vezes é praticado por indivíduos com pequenas porções, justamente para tentar ludibriar a repressão estatal. Por isso, a análise da quantidade é sempre relativa, a partir da realidade local e demais circunstâncias, sob pena de se admitir a livre circulação de entorpecentes sem que exista tráfico, o que é logicamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

2ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja-SP - cep 07401-125

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500869-98.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500869-98.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2085820/2021 - DEL.POL.ARUJA, 17036059 - DEL.POL.ARUJA, 580/21/201 - DEL.POL.ARUJA, 2085820 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITORIA BARBOSA DOS SANTOS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

A) RELATÓRIO

VITORIA BARBOSA DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, incisos III (cometida em transporte público), V (tráfico entre Estados da Federação) e VI (sua prática envolveu criança). Segundo a denúncia, "no dia 28 de março de 2021, por volta das 17h, na altura do Km 204 da Rodovia BR 116 (Rodovia Presidente Dutra), sentido Rio de Janeiro, bairro Jardim Joia, nesta cidade e comarca de Arujá/SP, a indiciada VITORIA BARBOSA DOS SANTOS, qualificada às fls. 06 e 21/22, transportava e trazia consigo, em transporte público, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 29 (vinte e nove) tijolos de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com massa líquida de 23,4 kg (vinte e três quilogramas e quatrocentos gramas), substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, conforme auto de apreensão de fls.

11/12, laudo de Constatação de fls. 14/17 e laudo de exame químico-toxicológico a ser juntado" (fls. 81). Foi notificado (fls. 170/171) e apresentou defesa prévia (fls. 193/194). Recebida a denúncia (fls. 195), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado. Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu o acolhimento dos pedidos, nos termos da denúncia. Em síntese, a defesa requereu a absolvição, sustentando que as provas são precárias.

B) ANÁLISE DO CASO CONCRETO

Imputa-se a prática do seguinte crime da Lei 11.343/06:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos)

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

O fato existiu. A materialidade está comprovada pela prova oral produzida; boletim de ocorrência (fls. 7/10); auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); laudo de constatação provisório (fls. 14/16) e laudo pericial definitivo (fls. 165/167), que atestam que a substância encontrada era de uso proibido pela Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 (24 quilogramas de maconha em porções compactadas na forma de tijolo).

Também não há dúvida da autoria.

A testemunha Rodrigo Duarte da Silva disse em sede policial que "Que é policial rodoviário federal e juntamente com seu colega de trabalho realizavam fiscalização de rotina na praça do pedágio de Arujá, sentido São Paulo/Rio de Janeiro, localizada no KM 204 da Rodovia Presidente Dutra, quando em dado momento, passou pelo local um ônibus de viagem da Viação Cometa AS, com itinerário São Paulo/SP a Juiz de Fora/SP e decidiram realizar a abordagem. O depoente e seu colega de trabalho ingressaram no interior do coletivo e passaram a entrevistar os passageiros, quando em dado momento, passaram a entrevistar passageira da poltrona 15, que foi identificado VITORIA B DOS SANTOS, a qual estava acompanhada de sua filha ANA KELLY BARBOSA FERNANDES de cinco anos de idade, contudo, salienta o depoente, que referida passageira demonstrou certo nervosismo em suas respostas, por isso, decidiram realizar a vistoria nas mochilas em que VITORIA trazia consigo. Ao proceder a busca no interior das mochilas, o depoente localizou 09 tabletes de substância esverdeada, aparentando ser maconha. Então, após a localização das substâncias, indagou VITORIA sobre os itens localizados, tendo ela prontamente confessado que estava transportando drogas, esclarecendo, ainda, que havia chegado em São Paulo na data de ontem, que ficou hospedada em um hotel e, nesta data

recebeu as substâncias de uma pessoa desconhecida na Rodoviária de Campinas/SP e que iria levá-la para a Rodoviária em Juiz de Fora, onde uma terceira pessoa iria manter contato e pegar as drogas com ela, para tanto, tal pessoa iria lhe pagar a quantia de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). O depoente salienta, ainda, que através das passagens localizadas em posse de VITORIA, foi possível identificar que ela trazia bagagens no compartimento de carga do coletivo, as quais estariam identificadas com os números de etiquetas 968757 e 968758, e então realizaram a vistoria nas referidas malas, onde foram localizados outros 20 tabletes de substâncias aparentando se Maconha. Por fim, informa que em posse de VITORIA, também foram localizados um celular e a quantia de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais). Diante todo o exposto, o depoente proferiu voz de prisão à VITORIA e, após o termino da fiscalização, o ônibus e os demais passageiros foram liberados para seguir viagem, enquanto VITORIA, sua filha, as drogas, o celular e demais objetos foram apresentados nesta unidade, onde a Autoridade Policial para que fossem adotadas as medidas de polícia judiciária.”.

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que fazia abordagem de rotina em ônibus. Nas entrevistas com passageiros a ré demonstrou muito nervosismo, não sabia exatamente por onde tinha ido e o que iria fazer. Estava com uma filha pequena, a todo momento mexia em uma bolsa. Na bolsa, junto com as coisas da filha haviam dois tijolos de maconha. Tinha outra bolsa de mão com mais sete tijolos, e comprovantes de bagageiro. Na mala do bagageiro encontraram mais droga. Ela disse que veio de Juiz de Fora até o Tietê, depois Campinas. Em Campinas pegou a droga e no dia seguinte foi para o Tietê, foi abordado no ônibus com destino a Juiz de Fora. Acredita que a filha tinha 4 anos. Não disse de quem era a droga, nem quem iria buscar. Disse apenas que pegou a droga com um suposto Uber, Aluvides Miranda. Tinha um valor pequeno de dinheiro. Ele disse que receberia mil e quinhentos reais. Ela disse que tinha ciência de que estava transportando droga desde quando saiu de sua cidade. Ela disse que teria

A testemunha Luis Bento Sabara disse em sede policial que “Que o depoente é policial rodoviário federal e juntamente com seu colega de trabalho realizavam fiscalização de rotina na praça do pedágio de Arujá, sentido São Paulo/Rio de Janeiro, localizada no KM 204 da Rodovia Presidente Dutra, quando em dado momento, passou pelo local um ônibus de viagem da Viação Cometa, com itinerário São Paulo/SP a Juiz de Fora/SP e decidiram realizar a abordagem. Que então ingressaram no interior do coletivo e começaram a entrevistar os passageiros, quando em dado momento, passaram a entrevistar passageira da poltrona 15, que foi identificada VITORIA B DOS SANTOS, a qual estava acompanhada de sua filha ANA KELLY BARBOSA FERNANDES de cinco anos de idade, contudo, referida passageira demonstrou certo nervosismo em suas respostas, por isso, decidiram realizar a vistoria nas mochilas em ela trazia consigo. Ao proceder a busca no interior das mochilas, o colega do depoente localizou 09 tabletes de substância esverdeada, aparentando ser maconha. Então, após a localização das substâncias, indagaram a passageira sobre os itens localizados, tendo ela prontamente confessado que estava transportando drogas, esclarecendo, ainda, que havia chegado em São Paulo na data de ontem, que ficou hospedada em um hotel e, nesta data recebeu as substâncias de uma pessoa desconhecida na Rodoviária de Campinas/SP e que iria levá-la para a Rodoviária em Juiz de Fora, onde uma terceira pessoa iria manter contato e pegar as drogas com ela, para tanto, tal pessoa iria lhe pagar a quantia de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Através das passagens localizadas em posse de VITORIA, foi possível identificar que ela trazia bagagens no compartimento de carga do coletivo, as quais estariam identificadas com os números de etiquetas 968757 e 968758, e então realizaram a vistoria nas referidas malas, onde foram localizados outros 20 tabletes de substâncias aparentando se Maconha. Por fim, o depoente informa que em posse de VITORIA, também foram localizados um celular e a quantia de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais). Diante todo o exposto, foi dada voz de prisão à VITORIA e, após o termino da fiscalização, o ônibus e os demais passageiros foram liberados para seguir viagem, enquanto VITORIA, sua filha, as drogas, o celular e demais objetos foram apresentados nesta unidade, onde a Autoridade Policial para que fossem adotadas as medidas de polícia judiciária. ”.

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que em fiscalização de rotina abordou o ônibus. A ré estava nervosa, o que foi percebido assim que ingressou no ônibus. Revistou sua bagagem e ela estava levando alguns tabletes de droga na bagagem de mão. Na bagagem do bagageiro encontrou mais maconha. A revista foi feita pelo depoente junto com seu colega. Não se recorda do que ela disse exatamente, mas teria dito que iria receber quantidade de dinheiro. O ônibus tinha destino a uma cidade de Minas Gerais. Ela estava com uma criança, sua filha, que deveria ter entre 5 e 6 anos, até foi chamado o Conselho Tutelar. Não se recorda se ela tinha dinheiro, acha que havia alguma coisa. Ela não disse quem seria o dono da droga, o que é comum nesses situações por medo de represália.

A ré Vitoria Barbosa dos Santos permaneceu em silêncio na fase policial. Em Juízo, admitiu os fatos. Trabalhava vendendo água em Juiz de Fora. Conheceu uma pessoa que ofereceu dinheiro para buscar uma mala em São Paulo, não sabia o que era. Só foi perceber que era droga quando chegou na rodoviária em Campinas, local onde pegou a mala de uma pessoa que parecia varrer a rua. Quando foi abordada confessou aos policiais. Iria receber R\$1.200,00. Uma suposta pessoa em Juiz de Fora iria estar aguardando quando recebesse a bolsa. Estava com sua filha de 5 anos, pois não sabia o que era. Queria desistir quando chegou em Campinas, mas o moço disse que não poderia desistir, e então pegou o ônibus e saiu. Sua filha tem 5 anos e o outro filho tem 1 ano, que atualmente está com a mãe de seu ex-marido. Não deixou a mala na rodoviária pois ficou com medo. Não tem notícia de sua família, apenas. Embora a inocência deva ser presumida, ao final da instrução a acusação cumpriu seu ônus de demonstrar os fatos alegados na denúncia.

Com efeito, os policiais confirmaram em Juízo que fizeram abordagem de rotina em ônibus no pedágio de Arujá e notaram nervosismo da ré. Em revista em sua bolsa de mão encontraram maconha, e outras porções em segunda bolsa de mão e mala que estava no bagageiro. O ônibus tinha destino a Juiz de Fora. Estava com sua filha de aproximadamente 5 anos.

Não há nada nos autos que evidencie que o agente de segurança tenha motivo para incriminar o réu de forma proposital. Por isso, deve prevalecer a versão do agente público, que age presumidamente na forma da lei, e cujo relato é coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas existentes no processo. A jurisprudência é farta nesse sentido.

Por outro lado, o réu não trouxe qualquer elemento que contrariasse tais premissas, sendo certo que o ônus da "prova da alegação incumbirá a quem a fizer" (art. 156, CPP). Ao contrário, admitiu a prática do delito, confissão que está em conformidade com os demais elementos dos autos. Disse que veio de Juiz de Fora para buscar uma mala, e chegando em Campinas descobriu que era droga. Ficou nervosa, mas continuou a viagem.

Por outro lado, a negativa da defesa não está amparada em qualquer elemento probatório, sendo certo que o ônus da "prova da alegação incumbirá a quem a fizer" (art. 156, CPP). A sentença deve se basear nas provas existentes nos autos. Se não existem elementos concretos para dar credibilidade à negativa diante das provas em sentido contrário, não há como acolher a versão da defesa e presumir que o agente de segurança tenha "forjado" a droga.

Ademais, o tráfico de drogas não se consuma apenas com o ato típico de "venda". Se o acusado pratica qualquer uma das 18 condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/06 terá incorrido no crime, inclusive na hipótese de apenas "ter em depósito", "guardar" ou "trazer consigo" a droga.

Mesmo a conduta de "oferecer" não exige a finalidade lucrativa, pois a lei tipifica as condutas praticadas "ainda que gratuitamente". Na realidade, o intuito de lucro é apenas uma circunstância negativa que justifica aumento da pena. Por isso, não se exige um elemento subjetivo especial, ou seja, a demonstração da intenção específica de praticar atos de mercancia. Basta o dolo genérico, a consciência e vontade de realizar alguma das ações que configuram o crime e dispensam intenção de venda.

O elemento subjetivo é determinante apenas para se descartar a hipótese de porte ou guarda da droga para uso pessoal, o que ensejaria a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Segundo o §2º deste dispositivo, "Para

determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Sobre o tema, é relevante observar que o tráfico muitas vezes é praticado por indivíduos com pequenas porções, justamente para tentar ludibriar a repressão estatal. Por isso, a análise da quantidade é sempre relativa, a partir da realidade local e demais circunstâncias, sob pena de se admitir a livre circulação de entorpecentes sem que exista tráfico, o que é logicamente impossível.

Feita essa ressalva, no caso concreto a quantidade não era compatível com a figura de mero usuário, ao menos para a realidade local. A própria ré admitiu que estava transportando a droga, do que tinha ciência.

Por fim, o simples fato de eventualmente ser usuário não afasta a configuração do tráfico, já que esses elementos não são excludentes.

Logo, está bem caracterizado o tráfico de drogas.

A prova é coesa e harmônica no sentido de que o réu conscientemente praticou o delito, realizando todos os elementos da norma incriminadora. Há tipicidade formal e material. Sua conduta foi contrária ao direito, era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seus atos e lhe era exigível comportamento diverso. A condenação é medida que se impõe.

C) DOSIMETRIA

O Juiz deve concretizar a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) analisando as particularidades da infração e condições pessoais do réu, buscando uma pena "suficiente para reprovação e prevenção" (art. 59, CP).

O objetivo é fixar uma pena justa para a situação concreta, diferenciando-a das inúmeras outras em que o mesmo crime poderia ser cometido, por diversas pessoas e seus motivos, diferentes formas de execução, consequências individuais e coletivas. Na primeira etapa, as frações de aumento devem incidir preferencialmente sobre o intervalo abstrato entre a pena mínima e a máxima. Esse critério é mais adequado especialmente em crimes nos quais a distância entre as penas mínimas e máximas é expressiva, tal como no tráfico de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. Se aplicada a fração de aumento sobre a pena mínima, a reprimenda nunca iria superar 10 anos de reclusão na primeira fase, mesmo em casos graves (aumento de 8/8). Isso deixaria de considerar toda a margem de variação prevista pelo legislador e tornaria a pena injusta.

Assim, "embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos" (grifei).

Nos crimes da Lei 11.343/06 merecem destaque ainda "a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" (art. 42). A ré é primário.

A quantidade de drogas autorizam o aumento da pena base (24kg de maconha), dado seu maior potencial destrutivo e viciante, acarretando igualmente maiores transtornos sociais e esforços do Poder Público em combatê-los.

Diante dessas circunstâncias negativas, majoro a pena base em 2/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima (ou seja, 10 anos), fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Verifico a atenuante da confissão, o que enseja redução da pena em 1/6. A pena intermediária é de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Incide a causa especial de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V), lembrando-se que para sua caracterização "é desnecessária a efetiva transposição de

fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual" (Súmula 587, STJ).

Esse elemento por si só justifica aumento da pena em 1/5, acima da fração mínima (1/6), por envolver não apenas o abastecimento de outro ponto de venda de drogas, mas também a articulação entre dois grupos criminosos e a consolidação de rotas da tráfico. Isso é especialmente sensível na Comarca, que fica nas margens da Rodovia Presidente Dutra, com todas as graves implicações sociais inerentes, exigindo-se maior repreensão pelo Estado.

Considerando que incide também a causa especial de aumento do tráfico em transporte público (art. 40, III), majoro a pena em 1/3, atingindo 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Não verifico a causa especial de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas. Embora a ré estivesse na companhia de sua filha, sua conduta não envolveu a corrupção de menor, ou seja, o efetivo envolvimento da criança na prática delitiva, o que seria impossível pela idade. Esse é o alcance da causa especial de aumento, ou seja, punir mais severamente quem induz o adolescente ou criança no mundo criminoso, do que não se trata a hipótese. Em sentido oposto, a presença da filha na viagem indica na realidade vulnerabilidade social, que não implica em maior reprovação da conduta.

Sendo a ré primária e inexistente outra ação penal em curso, viável a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06). O fato de ter praticado tráfico interestadual não implica necessariamente que o réu integre organização criminosa, pois não se descarta que sua colaboração com o grupo tenha sido apenas eventual, ou pelo menos não há prova decisiva em sentido contrário. Contudo, ainda que de maneira esporádica, a ré tinha ciência que estava colaborando com grupos criminosos que fomentam o tráfico de maneira profissional, motivo pelo qual a redução deve ser feita no patamar mínimo (1/6).

Por isso, a reprimenda final é de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado (art. 33, CP), considerando a quantidade da pena e a existência de duas causas especiais de aumento.

Eventual detração penal (art. 387, §2º, CPP), se for o caso, deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, único com competência para verificar a presença ou não dos requisitos subjetivos.

D) CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR a ré VITORIA BARBOSA DOS SANTOS como incurso no art. 33, §4º, c/c art. 40, III e V, da Lei 11.343/06, na pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, regime inicial fechado, dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo.

Considerando o regime inicial estabelecido, o período já cumprido de prisão preventiva, a projeção do direito de progressão de regime pelo crime que não tem natureza hedionda, bem como o afastamento da causa especial de aumento relativa a corrupção de menores, que na realidade indica vulnerabilidade social, visando inclusive tutelar os direitos de sua filha, concedo à sentenciado a LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante obrigação de manter seu endereço e telefone atualizado nos autos. Expeça-se alvará de soltura.

Declaro o perdimento dos bens apreendidos em favor da União (dinheiro) (art. 63, I e §1º, Lei 11.343/06).

Fica o réu condenado ao pagamento das custas (art. 804, CPP), observada eventual gratuidade concedida nos autos.

Expeça-se certidão de honorários, se for o caso, ficando a remuneração arbitrada em grau máximo.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões e, oportunamente, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para destruição de eventual contraprova (art. 72, Lei 11.343/06) e comunique-se ao IIRGD e ao TRE.
Publique-se. Saem as partes intimadas em audiência. Cumpra-se.
Aruja, 30 de março de 2022.